[참 고] 법률행위에 의하지 않은 채권의 이전에 관하여

㉠ 법률의 규정에 의한 채권의 이전에 지명채권양도의 대항요건에 관한 민법규정이 적용되지 않으므로, 채무자로서는 채권의 이전에 관한 통지 등의 유무와 관계없이 「채권자지위를 상실한」 채권양수인의 청구를 거부할 수 있다.[2]

㉡ 양도금지의 특약이 있더라도 전부명령에 따라 채권이 이전될 수 있고, 제449조 제2항은 적용되지 않는다. 즉 집행채권자의 선·악의는 문제되지 않으며, 전부채권자로부터 그 채권을 양수한 이가 악의이거나 중대한 과실이 있었더라도 채무자가 양도금지특약을 근거로 채권양도의 무효를 주장할 수 없다.[3]

㉢ 채권이 양도되고 대항요건을 갖추면 채무이행을 구하는 소에서 양수인만이 정당한 당사자로서 당사자적격을 가지는데,[4] 압류 및 전부명령이 있는 경우에도 지급에 갈음하여 피압류채권이 압류채권자에게 이전되므로(민사집행법 제229조 제3항) 마찬가지이다. 한편 추심명령이 있는 경우에 관하여 종래 대법원은 채무자의 제3채무자에 대한 채권에 관하여 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 채무자는 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실한다고 보았는데,[5] 대판(전) 2025.10.23. 2021다252977이 "채무자의 제3채무자에 대한 채권에 관하여 추심명령이 있더라도 채무자가 제3채무자를 상대로 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하지 않는다고 보아야 한다"[6]라고 하며 판례를 변경하였다.[7]

제 2 관 채권양도

[3442] Ⅰ. 총 설

1. 의 의

(1) 채권양도란 종래의 채권자(양도인)가 「채권」을 동일성을 유지한 채 이전함을 내용으로 하는, 채권자와 채권자로 될 이(양수인) 사이의 계약을 말하는데, 채권이 동일성을 유지한다는 점에서 경개와 구별된다([3119] 참조).

(2) 현존하는 권리, 즉 채권을 직접 이전시키는 채권양도는 「처분행위」에 해당한다.[1]

(3) 대개 의무부담행위(원인행위)가 채권양도의 원인을 이루고,[2] 많은 경우에 채권양도는 원

1) 전부명령이 확정되면 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때에 피압류채권의 「권면액」만큼 채무자가 채무를 변제한 것으로 보는데(같은 법 제231조), 압류채권자는 독점적인 만족을 얻을 수 있는 반면, 제3채무자의 무자력의 위험을 부담한다.

2) 대판 2003.9.5. 2002다40456. 대판 2007.11.16. 2007다36537도 참조.

3) 대판 2003.12.11. 2001다3771.

4) 소송계속 중 채권이 양도되었다면 양수인의 소송참가 또는 소송인수에 의한 소송승계가 있어야 한다.

5) 대판 2000.4.11. 99다23888 등. 국세징수법에 의한 체납처분으로 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류하는 경우에도 마찬가지라고 본 대판 2009.11.12. 2009다48879도 참조.

6) 그 이유로, 채무자가 제3채무자를 상대로 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기하는 것은 추심명령에 위반되지 않고, 추심명령이 있다는 이유만으로 채무자가 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실한다고 볼 법률적 근거가 없다는 점, 채무자가 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하지 않는다고 보더라도 추심채권자에게 부당한 결과가 생긴다고 보기 어렵다는 점, 채무자가 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하지 않는다고 보더라도 제3채무자에게 불리하지 않고 오히려 응소 부담을 최소화할 수 있다는 점 및 추심명령에 따라 채무자가 당사자적격을 상실한다고 보면 분쟁의 일회적 해결과 소송경제에 반하고 추심채권자의 이익에도 부합하지 않는 결과가 발생할 수 있다는 점을 든다.

7) 소송의 경과는 다음과 같다: 원고는 피고를 상대로 주위적으로 불법행위에 기한 손해배상을 구하고, 예비적으로 부당이득반환을 구하는 소를 제기 → 원심은 추심명령에 따른 일부 당사자적격 상실을 이유로 주위적 청구의 소 중 일부를 각하하고 나머지 주위적 청구는 기각하며, 예비적 청구 중 일부를 인용 → 원심판결 선고 후 원고의 금전채권자가 '원고가 이 사건 소송으로 받을 판결원리금 등 채권'에 관하여 추심명령을 받았고, 성남세무서장이 원고의 부가가치세 등 체납액의 징수를 위하여 동일한 채권을 압류 → 피고는 상고이유로 이 사건 소송물인 채권에 관하여 원심판결 후 새로운 추심명령 등이 있었으므로 원고가 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하였다는 등으로 주장 → 대법원은, 원고가 이 사건 소로써 구하는 채권에 관하여 추심명령과 체납처분에 기한 압류가 있더라도 원고가 그 채권에 관하여 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실한다고 볼 수 없다는 이유로, 피고의 주장을 배척하고 상고를 기각.

1) 물권이 아니라 채권의 이전을 목적으로 한다는 점에서 물권행위와 다르지만 처분행위라는 점에서 물권행위와 같으므로 이를 준물권행위라고 한다.

에 대해서도 효력이 있다(제621조 제2항). 그런데 당사자 사이에 "반대약정이 없으면"[43] 부동산임차인은 임대인에 대하여 그 임대차의 등기절차에 협력할 것을 청구할 수 있다(제621조 제1항). 즉 임차인에게 채권적인 등기청구권이 인정된다(반대: 김형배 Ⅰ, 412면).

② 임차권등기를 마치면, 제3자가 임대인인 소유자로부터 임차부동산을 양수한 경우에, 종래의 임대차는 신 소유자와 임차인 사이에 존속하는 것으로 되어 신 소유자의 인도청구를 거절할 수 있다. 그런데 주택임대차법 제3조의4 및 상가임대차법 제7조와 달리 우선변제권이 인정되지 않지만, 임차보증금이 등기되면(부동산등기법 제74조 제5호) 임차부동산의 양수인에 대하여 임차보증금(특히 그 반환에 관한 동시이행관계)을 주장할 수 있다.

③ 특약이 없는 한 연체차임채권이 당연히 신 소유자에게 이전되지 않는데, 구 소유자와의 사이에 있었던 특약 중 등기사항(부동산등기법 제74조 참조)에 관해서는 그것이 등기되어야 신 소유자에게 대항할 수 있다.

④ 임차권등기를 마친 경우에, 당사자 사이에 다른 약정이 없는 한 임대차 종료 후 임대인의 임차보증금반환의무와 임차인의 임차권등기말소의무는 동시이행관계에 있으므로, 임차인은 임차권등기말소의무를 이행하거나 이행제공을 하여 상대방을 이행지체에 빠뜨려야 비로소 임차보증금에 대한 지연손해금의 지급을 청구할 수 있음은 당연하다.[44]

(3) 한편 건물의 소유를 목적으로 하는 토지임대차(즉 건물대지임대차)를 등기하지 않았더라도, 임차인이 그 지상건물을 등기하면[45] 제3자에 대하여 임대차의 효력이 있다(제622조 제1항).[46] 그러나 대지에 관한 적법한 임차권(적법한 임차권 양도나 전대차를 포함한다)이 없다면, 그 대지상의 건물에 관하여 등기하였더라도 제622조는 적용되지 않는다.[47][48]

한편 건물이 임대차기간의 만료 전에 멸실 또는 후폐(朽廢)한 경우에 토지임대차는 그 효력을 잃는다(같은 조 제2항).

(4) 임차인은 점유보호청구권을 행사하거나 임대인의 물권적 청구권을 대위행사하여 불법점유자를 배제할 수 있다. 나아가 임차권이 대항력을 취득하면, 임차권 자체에 기한 방해배제청구도 가능하다.[49]

---

43) 임대인의 동의를 요하던 의용민법과 다르다.

44) 대판 2024.12.12. 2024다261989.

45) 지상건물에 대한 소유권보존등기에 한한다는 견해로 이은영, 416면.

46) 토지임차인이 건물에 관하여 등기를 하면 그 건물의 부지이용권에 관해서도 공시되므로 토지의 이해관계인에게 불측의 손해를 주지 않는다는 취지에 기한 것이다. 그러나 토지등기부와 건물등기부가 별개로 존재하므로, 토지의 이해관계인은 토지의 현황을 둘러보고 그 지상에 건물이 있으면 건물등기부도 확인해야 하는 불편이 따른다. 관련하여 건물등기의 지번과 토지등기의 지번이 다른 경우에, 그 건물이 등기부상의 건물표시와 사회통념상 동일성이 있고 그것이 임차한 토지 위에 건립되어 있어서 쉽게 경정등기를 할 수 있는 경우라면 경정등기 전이라도 대항력을 갖추었다고 보아야 한다고 한 대판 1986.11.25. 86다카1119도 참조.

47) 대판 1975.7.30. 74다2032는, 제622조 제1항의 취지는, 토지임차인이 임차지상의 건물을 등기함으로써 임대차의 등기가 없더라도 제3자에게 임대차의 효력을 주장할 수 있다는 것이지, 그러한 건물을 취득한 이에게 당연히 임차권이 생긴다는 것은 아니라고 하였다.

48) **[건물대지임대차의 대항력에 관한 재판례]** ㉠ 대판 2003.2.28. 2000다65802 · 65819는, 제622조 제1항은 건물을 소유하는 토지임차인의 보호를 위하여 건물의 등기로써 토지임대차등기에 갈음하는 효력을 부여하는 것일 뿐이므로 임차인이 그 지상 건물을 등기하기 전에 제3자가 그 토지에 관하여 물권 취득의 등기를 한 때에는 임차인이 그 지상건물을 등기하더라도 그 제3자에 대하여 임대차의 효력이 생기지 않는다고 하였고, 대판 1996.2.27. 95다29345는, 임차인으로부터 건물의 소유권과 함께 건물의 소유를 목적으로 한 토지의 임차권을 취득한 이가 토지의 임대인에 대한 관계에서 임차권의 양도에 관한 그의 동의가 없어도 임차권의 취득을 대항할 수 있다는 것까지 규정한 것은 아니라고 하였다. ㉡ 대판 1994.11.22. 94다5458은, A가 대지와 건물의 소유자였던 B로부터 이를 임차하였는데 그 후 A가 그 건물을 강제경매절차에서 경락받아 대지에 관한 위 임차권은 등기하지 않은 채 건물에 관하여 A 명의의 소유권이전등기를 경료하였다면, A와 B 사이에 체결된 대지에 관한 임대차계약은 건물의 소유를 목적으로 한 토지임대차계약이 아니므로, 그 대지에 관한 A의 임차권은 제622조에 따른 대항력을 갖추지 못했다고 하였다.

49) 대판 2002.2.26. 99다67079는, 등기된 임차권에 「담보권적 권능」까지 인정하는바, 임대차기간이 종료되면 용익권적 권능은 임차권등기의 말소등기 없이도 곧바로 소멸하나 담보권적 권능은 곧바로 소멸하지 않고, 임차권자는 임대차기간이 종료한 후에도 임차보증

에, 이로써 소멸하였던 대항력이 당초에 소급하여 회복되는 것이 아니라 그 등기가 마쳐진 때부터 그와는 동일성이 없는 새로운 대항력이 발생한다.[101]

(2) 임차권등기의 비용은 임대인이 부담하고(법 제3조의3 제8항),[102] 임차권등기 후의 소액보증인은 법 제8조에 의한 우선변제권을 가지지 못한다(법 제3조의3 제6항).

(3) 임대인의 임대차보증금반환의무는 임차인의 임차권등기말소의무보다 먼저 이행되어야 할 의무이다.[103]

나. 당사자지위의 변동 [4257]

(1) 임대인지위의 승계(承繼)에 관하여 살펴본다.

① 임차주택의 양수인 기타 임대할 권리를 승계한[104] 이가 임대인의 지위를 승계하는 것(법 제3조 제4항)은 ―임대인이 임대권원을 상실함에 따라 임차권이 소멸하는 경우에 임차인을 보호하기 위한― 법률상의 당연승계로, 양수인은 임차권의 부담 있는 소유권을 취득한다.[105] 즉 임대주택이 양도된 경우에, 양수인은 주택의 소유권과 결합하여 임대인의 임대차계약상 권리 · 의무 일체를 그대로 승계하고, 보증금에 관한 권리 · 의무도 당연히 신소유자인 양수인에게 이전된다. 그 결과 양수인이 임대차보증금반환채무를 면책적으로 인수하고, 양도인은 임대차관계에서 탈퇴하여 임차인에 대한 임대차보증금반환채무를 면한다.[106] 이 경우 양도인은 양수인에게 보증금을 이전할 법정채무를 부담한다(담보책임에 관한 제575조 제2항도 참조). 그리고 승계시점 이전의 연체차임이나 손해배상채권은 승계되지 않는데(양창수 · 김형석, 571면),[107] 보증금에서 이를 공제할 수 있음

101) 대판 2025.4.15. 2024다326398. 따라서 '대항요건 구비 → 주택에 근저당권 설정 → 대항요건 상실 후 임차권등기'의 경우에, 경매절차에서 주택을 매수한 이는 ―근저당권이 소멸하면서 임차권도 소멸하므로(소멸주의: [2425] 참조)― 법 제3조의 임차주택 양수인에 해당하지 않는다.

102) 임차인은 민사소송으로 그 비용을 청구하거나, 상계의 자동채권으로 삼는 등의 방법으로 비용상환청구권을 행사할 수 있다(대판 2025.4.24. 2024다221455).

103) 대판 2005.6.9. 2005다4529는, 이미 사실상 이행지체에 빠진 임대인의 임대차보증금의 반환의무와 그에 대응하는 임차인의 권리를 보전하기 위하여 새로이 경료하는 임차권등기에 대한 임차인의 말소의무를 동시이행관계에 있는 것으로 해석할 것은 아니고, 특히 임차권등기는 임차인으로 하여금 기왕의 대항력이나 우선변제권을 유지하도록 해 주는 담보적 기능만을 주목적으로 하는 점 등에 비추어 그러하다는 입장이다.
한편 2023년 개정으로 법 제3조의3 제3항의 준용규정에 민사집행법 제292조 제3항이 추가됨에 따라 임차권등기명령이 송달되기 전에도 임차권등기명령을 집행할 수 있게 되었다.

104) 예: 미등기건물의 사실상 양수인(대판 1987.3.24. 86다카164).

105) **[임대인지위의 승계 여부에 관한 재판례]** ㉠ 법 제3조 제4항을 적용하기 위하여 주택을 임대할 권리나 이를 수반하는 권리를 종국적 · 확정적으로 이전받아야 하는바, 임대차의 목적인 주택을 신탁법에 따라 신탁한 경우의 수탁자도 이에 해당한다(담보목적의 신탁에 관한 대판 2002.4.12. 2000다70460). 임차인이 임차주택의 소유권을 취득한 경우에도 같은 법리가 적용되어 임차인의 보증금반환채권은 혼동으로 인하여 소멸한다(대판 1996.11.22. 96다38216). 반면 후순위저당권의 실행으로 목적부동산이 경락되어 선순위저당권이 함께 소멸한 경우에, 후순위저당권자에게 대항할 수 있는 임차권이라도 소멸된 선순위저당권보다 뒤에 등기되었거나 대항력을 갖춘 임차권은 함께 소멸하므로, 이 경우의 경락인은 임차주택의 양수인 중에 포함되지 않고, 따라서 임차인은 경락인에 대하여 그 임차권의 효력을 주장할 수 없다(대결 1990.1.23. 89다카33043). ㉡ 임대인이 임차주택의 소유권을 담보목적으로 이전하더라도 임대인지위의 승계문제는 발생하지 않지만(대판 1993.11.23. 93다4083. [2532]에서 본 것처럼 담보제공자인 임대인의 점유할 권리가 소멸하지 않기 때문이다), 담보권의 실행에 의하여 양도담보권자가 종국적으로 임차주택의 소유권을 취득하면, 임대인지위의 승계가 일어난다. 그리고 임대인인 명의신탁자가 명의신탁에 의하여 임차주택의 소유권을 명의수탁자에게 이전한 경우에도 임대인지위의 승계문제는 발생하지 않는다고 할 것이다. 다만 대판 1999.4.23. 98다49753은, 주택의 명의신탁자가 임대차계약을 체결한 후 명의수탁자가 명의신탁자로부터 「주택을 임대할 권리」를 포함하여 주택에 대한 처분권한을 「종국적으로 이전받는」 경우에, 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마친 이상 명의수탁자는 법 제3조 제2항에 의하여 임차인과의 관계에서 그 주택의 양수인으로서 임대인의 지위를 승계하였다고 보았다. ㉢ 대판 2021.10.28. 2021다238650: "주택의 공동임차인 중 1인이라도 주택임대차보호법 제3조 제1항에서 정한 대항력요건을 갖추게 되면 그 대항력은 임대차 전체에 미치므로, 임차건물이 양도되는 경우 특별한 사정이 없는 한 공동임차인에 대한 보증금반환채무 전부가 임대인지위를 승계한 양수인에게 이전되고 양도인의 채무는 소멸한다. 이러한 법리는 계약당사자와 사이에 공동임차인의 임대차보증금 지분을 별도로 정한 경우에도 마찬가지이다."

106) 대판 2003.7.25. 2003다2918(다만 주택임차인이 법인인 경우에 주택양수인이 임대인의 지위를 당연히 승계하지는 않는다고 하였다); 대판 2018.12.27. 2016다265689(다만 "임차주택의 양수인에게 대항할 수 있는 임차권자라도 스스로 임대차관계의 승계를 원하지 아니할 때에는 승계되는 임대차관계의 구속을 면할 수 있다고 보아야 하므로, 임대차기간의 만료 전에 임대인과 합의에 의하여 임대차계약을 해지하고 임대인으로부터 임대차보증금을 반환받을 수 있으며, 이러한 경우 임차주택의 양수인은 임대인의 지위를 승계하지 아니한다"); 대판 2022.3.17. 2021다210720.

107) 상가임대차에 관한 대판 2008.10.9. 2008다3022 참조.